

1500047-21.2022.8.26.0262

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FÁBIO APARECIDO TIRONI

Comarca: Itaberá

Foro: Foro de Itaberá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... poder de arma de fogo, realizava o tráfico de drogas no município de Itaberá. Nestas circunstâncias, na data dos fatos, policiais civis e militares receberam notícia indicando que KAUÃ havia efetuado disparos de arma de fogo e que estava promovendo o tráfico de drogas. Desta feita, os agentes dirigiram-se até o local apontado, e ao avistarem o denunciado ordenaram que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaberá

Foro de Itaberá

Vara Única

Rua Coronel José Pedro de Lima, 266, Itabera - SP - cep 18440-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500047-21.2022.8.26.0262 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500047-21.2022.8.26.0262

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FÁBIO APARECIDO TIRONI

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, já qualificado nos autos em epígrafe, que apura a suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 14 e 15 da Lei Federal nº 10.826/03 e art. 180 do Código Penal. Segundo consta na denúncia de fls. 98-102, no dia 10 de março de 2022, na Rua José

Antunes, nº 64, Vila Dom Silvio, na cidade e comarca de Itaberá, KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, vulgo "Gaguinho", trazia consigo, para fins de fornecer a terceiros, e para venda, uma porção da substância popularmente conhecida como "maconha" com peso de 12,73g (doze gramas e setenta e três centigramas), substância essa que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também, que nas mesmas condições de tempo e lugar, KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, vulgo "Gaguinho", portava um revólver marca Rossi, calibre 22, municiado com 07 (sete) cartuchos, sendo 05 (cinco) intactos, e (02) dois deflagrados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, vulgo "Gaguinho", disparou arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela.

Consta, por fim, que em data incerta, porém, entre os dias 03 e 10 de março de 2022, KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, vulgo "Gaguinho", adquiriu, recebeu, transportou, e ocultou, em proveito próprio o revólver marca Rossi, calibre .22, de numeração 346296, sabendo que se tratava de produto de crime.

Sustentou o Ministério Público que "(...) o denunciado KAUÃ HENRIQUE, sempre em poder de arma de fogo, realizava o tráfico de drogas no município de Itaberá.

Nestas circunstâncias, na data dos fatos, policiais civis e militares receberam notícia indicando que KAUÃ havia efetuado disparos de arma de fogo e que estava promovendo o tráfico de drogas. Desta feita, os agentes dirigiram-se até o local apontado, e ao avistarem o denunciado ordenaram que permanecesse parado para revista pessoal. Antes, porém, de realizarem a busca pessoal, foi encontrada uma porção da droga, que estava sob um boné, numa mureta ali existente, e ao lado, um desfiador/triturador de tabaco. Ato contínuo, o denunciado foi submetido a revista, ocasião em que foi encontrado nos bolsos de sua bermuda, várias embalagens plásticas comumente utilizadas para armazenar a droga fracionada, três lâminas de barbear e uma nota de R\$ 20,00 (vinte reais). Logo após a revista, quando o denunciado estava sendo algemado, derrubou um revólver calibre 22, que estava escondido em suas partes íntimas. Inquirido pelos policiais, o denunciado admitiu a propriedade da droga encontrada e do revólver. O contexto no qual a droga foi apreendida, mormente no que diz respeito a grande quantidade de embalagens normalmente utilizadas para acondicionar o entorpecente, as lâminas e o desfiador de tabaco apreendidos, aliados às notícias da prática delitiva envolvendo o denunciado, evidenciam claramente que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito. O laudo pericial (fls. 68/72) concluiu que a arma de fogo foi utilizada para disparo recente. Além disso, a apreensão de cartuchos deflagrados municiando o revólver, somados às notícias recebidas pelos agentes, evidenciam que denunciado utilizou o artefato para disparos momentos antes de sua abordagem. Enfim, é dos autos também, que o denunciado adquiriu, recebeu, e ocultou o revólver marca Rossi, calibre .22, de numeração 346296, em proveito próprio, sabendo que se tratava de produto de crime. Isso porque, depois da subtração do mencionado revólver no dia 03 de março de 2022, (Boletim de ocorrência n.º: AM8157-1/2022 – fls. 84/86), pessoa não identificada ofereceu-o ao denunciado, que o recebeu e o ocultou sabendo ser produto de crime, pela simples natureza do artefato, que só pode ser obtido e mantido sob a posse, se de acordo com autorização da autoridade competente.".

Preso em flagrante na data dos fatos (fl. 01), foi concedido liberdade provisória ao réu em audiência de custódia realizada no dia seguinte (fls. 44-48).

O Ministério Público ofereceu denúncia em 31.03.2022 (fls. 98-102).

Em fl. 104 foi determinada a notificação do réu para os fins do art. 55 da Lei 11.343/06.

O denunciado apresentou defesa preliminar por intermédio de defensor dativo (fls. 109-111) e foi notificado (fl. 115).

A denúncia foi recebida no dia 21.06.2022. Na oportunidade designada audiência de instrução, debates e julgamento, e ainda, foi determinada a citação do réu (fls. 118-119).

O réu foi citado (fl. 158).

Em audiência virtual realizada na forma do Comunicado CG nº 284/2020, bem como com

base no permissivo do art. 6º, § 2º da Resolução nº 312/2020 do Conselho Nacional de Justiça, foi produzida prova testemunhal e o réu foi interrogado. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, ao passo a defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com regime diverso do fechado. É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Considerações iniciais:

Antes de examinar o mérito da pretensão punitiva, constato que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), não havendo nulidades a sanar nem irregularidades a suprir. Assim, presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

2.2. Da prova testemunhal:

A prova testemunhal colhida pela autoridade policial e produzida durante a instrução em juízo foi no seguinte sentido:

A testemunha HÉLIO NAZARETH DE LIMA, Policial Civil que conduziu o réu até a delegacia, em fase inquisitorial declarou (fl. 06): “a polícia militar recebeu informação que um indivíduo de apelido Gaguinho, nome Kauan, pena vila Don Silvío, estaria esse indivíduo traficando, e inclusive efetuando disparos de arma de fogo no local, que esse indivíduo detém contra ele várias informações de dias anteriores que o mesmo praticando o tráfico de entorpecente e sempre anda armado. Que o depoente que é policial civil desta unidade policial, seguiu até o local, Vila Don Silvío, em frente ao bar da nega, Rua José Antunes e com o apoio do policial Militar Ramos ao chegarem no local, o depoente, viu que o suspeito estava com outras três pessoas, e nesse momento foi dado voz para os mesmos encostarem, e no local havia uma mureta, e um boné sobre ela, que quando o depoente encostou a mão no boné sobre a mureta, viu que caíram do local ao chão, o entorpecente, uma porção de maconha, e nesse momento Gaguinho já falou que a droga era dele, razão pela qual foi iniciada uma revista pessoal no mesmo, e no bolso traseiro lado direito da bermuda do mesmo o depoente encontrou várias embalagens, tipo sacolé, d que normalmente são utilizadas para embalar droga para venda, continuando a revista no bolso ainda havia uma gilete, e uma cédula única de R\$20,00, e nesse momento perceberam que o mesmo estava muito nervoso, e quando foram algemá-lo caiu a arma que estava na cueca do mesmo, tratando-se de um revólver, calibre 22, niquelado, cabo de madeira, amadeo rossi, municiado com sete munições, sendo cinco intactas e duas deflagraadas. Perguntado de quem é essa arma, e ele falou que carregava para defesa. Havia no chão um deschavador que estava no chão. Foi então dada voz de prisão ao mesmo, que nada mais falou e levado até a delegacia de polícia. Os outros dois indivíduos foram liberados no local, pois nada foi encontrado com os mesmos.”. Em juízo relatou que: “no dia em questão a polícia militar recebeu denúncias de que o “gaguinho” se encontrava na via Dom Silvío, em um bar, traficando entorpecentes e realizando disparos de arma de fogo; a polícia militar pediu apoio e foi em uma viatura da polícia civil, separada, ajudar na abordagem; ajudou na abordagem do acusado e de mais três companheiros do réu; em cima de uma mureta, perto do réu, quando bateu no boné, caiu uma porção de “maconha”; em revista pessoal, foi encontrado “sacólés”, que são utilizados para embalar drogas e algumas “gilletes”; mencionou que o réu estava nervoso; foram algemar o acusado e de suas partes íntimas “caiu” a arma de fogo, com 7 munições na câmara, 5 intactas e 2 deflagraadas; foram conduzidos à delegacia de polícia e foi feito a prisão em flagrante; já haviam notícias prévias de que o acusado andava armado; acusado alegou que andava com a arma por defesa própria; réu não foi agressivo e a abordagem foi educada, o nervosismo poderia se dar por estar com algo ilícito.” A testemunha ELISEU RAMOS, Policial Militar que acompanhou a prisão em flagrante do réu, em fase inquisitorial declarou que (fl. 08): “é policial militar e na data de hoje estava com a vtr I 54.315, e em patrulhamento pela vila Bandeirantes, quando um transeunte parou a viatura, para fazer uma denúncia de que um indivíduo na Vila

Dom Silvío, próximo ao bar da neta tinha efetuado disparos de arma de fogo. Que, seguiram para o local juntamente com policiais civis que seguiram em viatura própria. Inclusive, o indivíduo denunciado vulgo Gaguinho há várias denúncias de que o mesmo trafica e anda armado. Chegando no local, as duas viaturas e foi abordado ele e mais três indivíduos, e defronte a ele em uma muretinha, encontraram um boné, e embaixo do boné estava um deschavador e uma porção de maconha, e o mesmo afirmou que era para seu uso, que no bolso em revista foram encontrados R\$20,00 e um deschavador, e no momento em que o mesmo foi ser algemado, caiu dos órgãos genitais do mesmo um revólver, calibre 22, e o mesmo também confessou que a arma lhe pertencia, e que estava de posse da arma para se defender. Mas não declarou nada sobre disparo. Foi então conduzido preso algemado para a delegacia. Não houve resistência do mesmo, embora um pouco nervoso, mas veio de boa, sendo conduzido na viatura da polícia civil."

Em juízo aduziu que: "Estava em patrulhamento pela via Bandeirantes; um transeunte fez uma denúncia alegando que o "gaguinho" estaria de posse de arma de fogo e teria realizado disparos; encontrou com a viatura da polícia civil que foi ao apoio deles; próximo do "bar da nega" o "gaguinho" foi abordado e em seu bolso tinha uma nota de 20 e algumas "gilletes"; perto dele tinha um boné e nesse boné havia entorpecentes e um "dichavador"; quando o policial civil Hélio foi algemar o acusado, caiu de suas partes íntimas a arma de fogo; o acusado já tinha várias denúncias em seu desfavor; já haviam denúncias anônimas corroborando que o réu andava armado; nunca tinham encontrado com o réu antes nessas denúncias prévias mas nunca lograram êxito de encontra-lo."

Interrogado perante a Autoridade Policial o réu KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES exerceu o direito constitucional ao silêncio, senão vejamos (fls.09-10): "que está sem a presença de um advogado, e cientificado de seu direito de silêncio afirmou que irá falar somente em juízo."

Interrogado em juízo, por sua vez, o réu KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES confessou a prática dos fatos narrados na denúncia, sustentando que: "as acusações são verdadeiras; estava com as drogas no dia; iria embalar e depois vender; já tinha vendido antes, já estava há cerca de 1 ano na atividade de tráfico; recebia R\$200,00 reais pelo pacote de droga; a arma que portava no dia foi furtada em um sítio; estava "louco" e roubou a arma em um sítio que estava vazio; roubou também uma espingarda, mas, posteriormente a vendeu; andava com a arma calibre 22 desde o dia do furto; o disparo foi realizado em uma rua acima da rua que foi abordado; atirou em comemoração pela chegada de mais drogas; a "gillette" era usada para "picar" a droga; portava o pacote de "maconha" e 12g de "crack"; continuou a traficar após liberação em audiência de custódia."

Após essa breve exposição da prova testemunhal, passo a analisar individualmente as imputações formuladas em face do acusado.

2.3. Do suposto crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33):

De acordo com a denúncia de fls. 98-102, no dia 10 de março de 2022, na Rua José Antunes, nº 64, Vila Dom Silvío, na cidade e comarca de Itaberá, KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, vulgo "Gaguinho", trazia consigo, para fins de fornecer a terceiros, e para venda, uma porção da substância popularmente conhecida como "maconha" com peso de 12,73g (doze gramas e setenta e três centigramas), substância essa que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De início, é sabido que o tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública. Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 14-15 demonstra que foram apreendidas na posse do réu 12,95 (doze gramas e noventa e cinco centigramas) de "maconha" acondicionadas em uma porção, 01 (um) revólver da marca "Rossi", Calibre .22 com 05 (cinco) munições integras e 02 (duas) deflagradas, além de uma nota no valor de R\$ 20,00 (vinte reais), 02 (duas) embalagens de saquinhos

plásticos contendo diversos “sacólés”, 01 (um) “dichavador” e 03 (três) lâminas de “Gillete Wilkinson Sword” em uma caixinha de embalagem própria.

Anote-se que, conforme conclusão do laudo pericial definitivo de fls. 76-79 constatou tratar-se de substância entorpecente as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06), qual seja, “tetrahidrocannabinol”.

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES foi o autor do crime descrito na denúncia. Com efeito, o Policial Civil HÉLIO NAZARETH DE LIMA e o Policial Militar ELISEU RAMOS, de forma harmônica e coerente, relataram com detalhes a abordagem realizada no réu que culminou na apreensão das drogas que estavam em sua posse, bem como a existência de denúncias pretéritas do seu envolvimento com a prática de crimes, em especial de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Ademais, o réu KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES confessou em juízo que as drogas apreendidas eram de sua propriedade e destinadas ao tráfico, bem como que ele já estava envolvido com a traficância há cerca de 01 ano e até mesmo que voltou a vender drogas após ser liberado na audiência de custódia.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escoreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Ademais, nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre impossível, deve ser conferido às declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

Vale ressaltar, outrossim, que nada de concreto foi trazido pela defesa que afastasse a credibilidade dos depoimentos dos Policiais.

Ademais, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não a finalidade para o uso próprio. Nessa mesma ordem de ideias, conforme trecho do v. acórdão proferido na Apelação nº 0000926-20.2016.8.26.0616, “Por outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda”. (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

Ainda, em consonância com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico e drogas prescinde que o

rêu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga, especialmente porque o tipo penal é misto alternativo e a prática de qualquer conduta do núcleo do tipo caracteriza o delito. A propósito: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP - AC 20.239 - Rei. Geraldo Gomes-RT 584/347); "TÓXICOS - Tráfico - Prova de algum ato de comércio - Desnecessidade - Trazer consigo ou manter a droga em depósito para venda, ainda que futura - Suficiência, na medida em que a consumação do delito não exige qualquer resultado Recurso parcialmente provido para reduzir as penas impostas e estabelecer o regime inicial fechado." (Apelação Criminal n. 1.141.860-3/6 São Paulo 5ª Câmara Criminal Relator: Pinheiro Franco 14.02.08 V.U. Voto n. 10.277).

Assim, de rigor a condenação do réu pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.4. Dos supostos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 15):

De acordo com a denúncia de fls. 98-102 nas mesmas condições de tempo e lugar, KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, vulgo "Gaguinho", portava um revólver marca Rossi, calibre 22, municiado com 07 (sete) cartuchos, sendo 05 (cinco) intactos, e (02) dois deflagrados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. E ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, vulgo "Gaguinho", disparou arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. Na situação sob julgamento a materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14-15 que demonstra a apreensão de 01 (um) revólver da marca "Rossi", Calibre .22 com 05 (cinco) munições integras e 02 (duas) deflagradas, pelo laudo pericial de fls. 68-72 que constatou: "Teste de recentidade de disparo apresentou resultado positivo. Exames revelaram que a arma em questão é apta a efetuar disparos no estado em que se encontra", pelo laudo pericial de fls. 80-83 que concluiu que as 05 munições íntegras estavam aptas a serem disparadas, bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A autoria, da mesma forma, é conhecida e certa, recaindo sobre o réu KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, conforme se extrai dos depoimentos do Policial Civil HÉLIO NAZARETH DE LIMA e do Policial Militar ELISEU RAMOS, que confirmaram que o réu foi preso em flagrante portando a arma de fogo e que em momentos anteriores ele havia realizado disparos em via pública, conforme denúncias recebidas.

Ademais, destaque-se que o réu confessou a autoria do crime em questão, admitindo que portava a arma já há vários dias e que realizou os disparos para "comemorar" a chegada de novas drogas.

Vale ressaltar, sobre outro aspecto, que não há que se falar em absorção do crime de porte pelo crime de disparo, diante da inequívoca autonomia entre as condutas. Do que se infere das provas produzidas sob o crime do contraditório, o réu já portava a arma há vários dias, tendo consumado o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento. Por outro lado, o disparo em via pública ocorreu em momento posterior, mediante conduta diversa, após a consumação do crime anterior, inexistindo qualquer relação de meio e fim entre as condutas.

Em outras palavras, inaplicável no caso o princípio da consunção, uma vez que o crime de porte já estava consumado com o transporte pelo réu da arma em via pública por vários dias, quando ele, em nova conduta e com desígnio autônomo, decidiu efetuar disparos com essa mesma arma em local habitado.

Assim, no caso em discussão, os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo aperfeiçoaram-se em momentos distintos,

possuindo, portanto, desígnios autônomos e contextos diversos. Desta feita, não há que se cogitar a aplicação do princípio da consunção, uma vez que a absorção pretendida presume a ocorrência de delitos consumados num só contexto fático, induzindo à conclusão de que um delito serviu como preparação ou suporte ao cometimento de outro, ou seja, um crime-meio e um crime-fim, fatores que não se verificam no presente caso.

Nesse sentido é entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BEM JURÍDICOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas. Precedentes. 2. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, por tutelarem condutas e bem jurídicos diversos. 3. Agravo regimental provido, a fim de afastar a consunção entre os crimes previstos no art. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 e redimensionar a pena do recorrido para 3 anos e 6 meses de reclusão e multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. (AgRg no AREsp 1515023/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)”.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E DISPARO. CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo. 2. Concluindo o Tribunal de origem, com apoio no conjunto probatório dos autos, que os crimes de posse e de disparo de arma de fogo não foram praticados no mesmo contexto fático, porquanto se aperfeiçoaram em momentos diversos e com desígnios autônomos, a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1211409/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)”.

Não é outro o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Apelação – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (arts. 12 e 15, ambos da Lei 10.826/03) – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão do acusado – Depoimentos firmes e coerentes das testemunhas – Validade – Crime de mera conduta e perigo abstrato – Desnecessidade da comprovação do efetivo dano ao bem jurídico tutelado – Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção – Condutas praticadas em momentos distintos e provenientes de desígnios autônomos – Precedentes do TJ – Dosimetria – Penas-base fixadas acima do mínimo legal em razão da agravante da reincidência – Penas-base fixadas no mínimo legal, pois, nos termos do art. 68, do Código Penal, as circunstâncias agravantes devem ser valoradas apenas na segunda fase da dosimetria – Recurso do Ministério Público – Majoração da pena por ser a agravante da reincidência preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea – Descabimento – Preponderância de ambas as circunstâncias consideradas – Circunstância agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea – Recurso defensivo – Substituição penal – Inaplicabilidade – Ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal – Regime semiaberto mantido – Réu reincidente – Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido, contudo, sem reflexo na pena. (TJSP; Apelação Criminal 0005869-70.2017.8.26.0220; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaratinguetá - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)”.

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição com fundamento no princípio da consunção entre os delitos dos artigos 14 e 15, ambos da Lei 10.826/03, bem como pela causa excludente de ilicitude, consistente em legítima

defesa. Descabimento. 1. Absolvição. Impossibilidade. Princípio da consunção. Inocorrência. O acusado já transportava a arma de uso permitido, de calibre .38, marca Rossi, com numeração de série D887830, que é crime formal, de mera conduta, bastando a posse da arma de fogo para sua configuração. Ainda, não tinha, o réu, a posse da mencionada arma de fogo com o fim de efetuar o específico disparo. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção. Condutas praticadas em momentos distintos e provenientes de desígnios autônomos. Legítima defesa não configurada. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0000679-32.2017.8.26.0607; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 05/11/2019)".

Nesse cenário, se impõe a condenação do réu também pela prática dos crimes tipificados nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03.

2.5. Do suposto crime de receptação (CP, art. 180):

De acordo com a denúncia de fls. 98-102, em data incerta, porém, entre os dias 03 e 10 de março de 2022, KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, vulgo "Gaguinho", adquiriu, recebeu, transportou, e ocultou, em proveito próprio o revólver marca Rossi, calibre .22, de numeração 346296, sabendo que se tratava de produto de crime.

A materialidade do crime de receptação restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14-15 que demonstra a apreensão de 01 (um) revólver da marca "Rossi", Calibre .22 com 05 (cinco) munições integras e 02 (duas) deflagradas, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 84-86, bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A arma em questão era produto de furto, conforme consta do Registro de Ocorrência AM8157/2022 (fls. 84-86), o dono, e vítima do furto, era FELIPE AGIBERT BARBOSA FERNANDES, tendo a subtração ocorrido em sua fazenda, localizada no município de Itaberá/SP, na madrugada de dia 03 de março de 2022.

Portanto, tendo em vista que a arma apreendida estava em posse do réu e ele sabia ser produto de crime, resta evidente a existência do crime de receptação.

Além disso, o réu confessou, em juízo, saber que a arma era produto de crime e que portava ela desde o dia do furto. Alegou, inclusive, que foi ele mesmo o autor do furto. No entanto, há indicativos nos autos de que o acusado seja mero receptador, de modo que, em obséquio ao princípio do favor rei, deve ser reconhecido o crime de receptação, já que mais benéfico ao réu, nos termos, aliás, pleiteados pelo próprio Ministério Público.

Assim, o réu também deve ser condenado como incurso no art. 180 do Código Penal.

2.6. Considerações finais:

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03 e do art. 180 do Código Penal, todos em concurso material (CP, art. 69).

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, está analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o réu é imputável e

dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03 e art. 180 do Código Penal, todos em concurso material (CP, art. 69).

2.7. Dosimetria:

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Vale ressaltar que os crimes praticados em concursos tiveram as mesmas circunstâncias, razão pela qual será feita apenas uma dosimetria, destacando-se eventual circunstância diferenciadora, anotando-se que referida sistemática encontra-se em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito: "Observadas todas as três etapas da dosimetria, em relação a cada um dos delitos, separadamente ou não, sendo feitas as devidas diferenciações quando necessárias ou realizadas em conjunto para todos os delitos, quando aplicáveis, não há falar em ofensa ao princípio da individualização da pena pelo aproveitamento dos fundamentos, sem a necessidade de repetição, para evitar tautologia". (HC 285.530/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: conforme informações de fls. 160-161 o acusado registra uma condenação definitiva por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao apurado nos presentes autos (autos nº 1500330-78.2021.8.26.0262 - fatos ocorridos em 01.11.2021 - trânsito em julgado para a defesa em 26.07.2022), razão pela qual a presente circunstância será valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos dos crimes são aqueles inerentes aos tipos; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que os crimes foram praticados não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar dos crimes em questão; h) Comportamento da vítima: tratam-se de crimes sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: são normais à espécie. Diante de tais circunstâncias e sendo uma considerada negativa (antecedentes), fixo a pena-base nos seguintes termos: 06 anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06; 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03; 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime do art. 15 da Lei 10.826/03; 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime do art. 180 do Código Penal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Presente, contudo, as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"; STJ, Súmula nº 545) e da menoridade relativa (CP, art. 65, I - réu com 18 anos de idade na época dos fatos - nascido em 06.07.2003), de modo que, em obséquio a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, atenuo a pena-base e fixo intermediária no mínimo legal, ou seja, em: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06; 02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03; 02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime do art. 15 da Lei 10.826/03; 01 ano de reclusão e 10 dias-multa para o crime do art. 180 do Código Penal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, não sendo o caso de aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em relação ao crime de

tráfico de drogas diante dos antecedentes do réu que ostenta condenação definitiva por fato anterior (fls. 160-161) e da sua evidente dedicação a atividades criminosas. Sobre o ponto, anote-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso especial repetitivo (Tema nº 1.139) no sentido de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". No entanto, conforme consta do voto condutor da eminente relatora Ministra LAURITA VAZ, "(...) É relevante observar, ainda, que a interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de elementos inidôneos, como é o caso de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto (...)". No caso dos autos, a dedicação a atividades criminosas do réu está suficientemente comprovada nos autos, seja em razão de anterior condenação definitiva, seja pelo fato de ele estar envolvido com a traficância há mais de um ano e até mesmo em data posterior a sua soltura em audiência de custódia, conforme admitido no próprio interrogatório do acusado. Some-se a isso o emprego e porte ostensivo de arma de fogo, inclusive com disparos para comemorar a chegada de nova remessa de drogas, em mais uma demonstração de que o réu - a despeito da baixa idade - faz do crime o seu meio de vida e está cabalmente dedicado a atividades criminosas.

Em relação a todos os crimes, presente o concurso material (CP, art. 69), já que decorreram da prática de condutas autônomas, violadoras de bens jurídicos diversos e bem delimitados, conforme exposto de forma detalhada na fundamentação, impondo-se, portanto, o cúmulo das reprimendas, restando desse modo o réu definitivamente condenado às penas de 10 anos de reclusão e 530 dias-multa, estes fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Impede salientar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo serem observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto. No caso dos autos, contudo, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, notadamente os antecedentes do réu, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento da pena.

Diante da quantidade da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis (CP, arts. 44 e 77).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu KAUÃ HENRIQUE XAVIER ALVES pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03 e no art. 180 do Código Penal, todos em concurso material (CP, art. 69), às penas de 10 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 530 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV- DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

4.2. Antes de me manifestar sobre a prisão nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, considerando que o réu declarou em seu interrogatório que havia se mudado para o estado do Paraná, somado ao fato que a Defesa, embora tenha solicitado em audiência prazo para juntar comprovação do atual endereço do réu, ficou-se inerte, diante da possibilidade de ter ocorrido descumprimento das cautelares diversas da prisão, notadamente àquelas dos itens "c" e "d" do termo de

audiência de custódia (fl. 47), DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre o ponto.

4.3. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

4.4. Considerando a demonstração de que o dinheiro apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos nas fls. 18-19. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD.

4.5. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº 11.343/2006), bem como DECRETO o perdimento da arma apreendida e a sua destruição, caso as providências ainda não tenham sido adotadas.

4.6. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena.

4.6. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

4.7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itabera, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA